

被害者の承諾に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、乙の承諾を得て、乙から借り受けた乙所有の重機を丙に転貸していたが、同重機の修理のため一時これを丙から預かった際、乙の承諾を得て、丙に無断で、自己の借金の返済として同重機を自己の債権者に譲渡した。この場合、甲には、横領罪が成立する。
2. 甲は、自らが組長を務める暴力団の組員乙から、「暴力団を脱退したい。」との申出を受けたので、「落とし前として、指を詰めろ。」と言ひ、乙の承諾を得て、乙の右手小指の根元を出刃包丁で切断した。この場合、甲には、傷害罪は成立しない。
3. 甲は、乙との不倫関係を清算しようと考え、真実は、乙と心中するつもりはないにもかかわらず、乙に対し、「あの世で一緒になろう。私も君の後を追って死ぬから。」と言って心中を持ちかけ、その旨誤信してこれを承諾した乙に毒薬を手渡したところ、乙がそれを飲んで死亡した。この場合、甲には、自殺関与罪が成立する。
4. 甲は、知人乙から、「生活が苦しく刑務所に入りたいので、私から脅されたという事実をでっち上げて、私を告訴してほしい。」と依頼され、乙の承諾を得て、乙を脅迫罪で告訴した。この場合、甲には、虚偽告訴罪は成立しない。
5. 甲は、自らが刑務官を務める刑務所で受刑中の成人女性乙と恋愛関係になり、乙の承諾を得て、勤務中、同刑務所内において、乙と性交した。この場合、甲には、特別公務員暴行陵虐罪が成立する。

No73	被害者の承諾	正答率
共通R1-9	正解 5	53%

1 誤っている ★

まず、横領罪における「他人の物」とは、252条2項の場合を除き、他人の所有権に属すること、すなわち、他人の所有物を意味する。また、他人の占有する自己物に対して処罰を定める242条や262条の規定は、処罰範囲を拡張する例外規定であるから、明文の規定がないため横領罪に準用されない（最決昭52.3.25）。本記述の重機は、乙の所有物であり、転借人丙の所有物ではないため、甲が丙に無断で重機を自己の債権者に譲渡したとしても、丙に対する横領罪は成立しない。次に、甲は重機の所有者である乙の承諾を得て同重機を自己の債権者に譲渡しているところ、乙の承諾により横領罪の構成要件該当性が阻却されるので、乙に対する横領罪も成立しない。

2 誤っている

最決昭55.11.13（百選I22事件）は、「被害者が身体傷害を承諾したばあいに傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものである」としている。つまり、判例は、諸般の事情を総合考慮して、承諾を得た法益侵害行為が社会的に相当であるかどうかにより、違法性が阻却されるかどうかを判断している立場に親和的である。乙の承諾を得たとしても、暴力団の指詰め行為は社会的に相当といえるものではないから、違法性が阻却されず、甲には傷害罪が成立する。

3 誤っている

最判昭33.11.21（百選II1事件）は、本記述と同様の事案において、殺人罪が成立するとしている。その理由として、判例は、「本件被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に添わない重大な瑕疵ある意思であることが明らかである」ということを挙げている。

4 誤っている

大判大元12.20は、同意のある虚偽告訴行為に虚偽告訴罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、申告に告訴者・被告告訴者の一致が見られれば捜査の端緒として重視されやすく、国家の司法作用をかなり侵すこと、国家法益に対する罪である以上、同意のある虚偽告訴も構成要件に該当するということを挙げている。

5 正しい

特別公務員暴行陵虐罪は、主として公務の適正を保護法益とするものであるから、被害者の承諾があっても本罪の成立に影響しない。よって、甲には特別公務員暴行陵虐罪が成立する。したがって、本記述は正しい。なお、東京高判平15.1.29は、本記述と同様の事案において、本罪が成立するとしている。